

1502184-58.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... R\$ 5,00. Informou que foi preso por tráfico de drogas em 2014 e 2016, tendo cumprido pena e deixado a prisão em 2018. Declarou que estava trabalhando e longe da criminalidade, mas que a necessidade financeira o fez retornar ao tráfico.

Em juízo, confessou que estava traficando por necessidade e agiu por "emoção", pois não arrumava emprego em razão da pandemia. Afirmou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1502184-58.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502184-58.2021.8.26.0537 Controle nº 1569/2021

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DA SILVA MACEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JONATHAN DA SILVA MACEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 15:30 horas, na Rua Jurupis, altura do n.º 15, Bairro Serraria, adquiriu, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína, "crack" e lança-perfume (*****aditamento em audiência, este último não constou da denúncia), drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 38/41).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 85/86), sendo recebida a denúncia em 25.02.22 (fls. 89/90). Tendo em vista que em razão da pandemia (Coronavírus/Covid-19) foi instituído o Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau, bem como determinada a suspensão das audiências presenciais no período de 25 de março de 2020 a 18 de março de 2022 (Provimentos CSM n.º 2549/20, n.º 2554/20, n.º 2556/20, n.º 2560/20, n.º 2561/20, n.º 2563/20; Provimentos da Presidência n.º 2575/20, n.º 2580/20 e CSM n.º 2583/20, n.º 2587/21, n.º 2596/21, n.º 2605/21, n.º 2612/21, n.º 2613/21, n.º 2616/21, provimento CSM n.º 2618/21, n.º 2624/21, n.º 2629/21, n.º 2645/21, n.º 2646/22 e n.º 2650/22) e considerando as diretrizes estabelecidas pelo provimento

CSM n.º 2564/2020, que disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foi designada audiência virtual (Comunicado CG 284/2020, Resolução 314 do CNJ e Provimento CSM 2557/20). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arrolada pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com fixação de regime fechado por ser reincidente específico, afastando-se a redução do art. 33, §4.º.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência, desclassificação para os crimes do art. 28 ou 37 da Lei de Drogas ou em caso de eventual condenação, que a pena seja fixada no mínimo legal, compensação das confissões com a reincidência, a aplicação da redução do art. 33, §4.º, fixação de regime diverso do fechado e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 04), o réu permaneceu confessou a prática do crime. Disse que havia sido demitido do trabalho como pizzaiolo, há cerca de duas semanas atrás, e aceitou a proposta de um homem desconhecido para trabalhar na "biqueira" para receber R\$ 50,00 mais 10% do valor das vendas. Narrou que naquele dia foi até o ponto de traficância, por volta das 15:00 horas, o desconhecido lhe entregou alguns entorpecentes, os quais guardou no bolso, e mostrou um cano do outro lado da rua, onde havia mais entorpecentes, o mandou permanecer no local até as 22:00 horas e foi embora. Relatou que foi abordado pelos policiais pouco tempo depois, que estes localizaram as drogas em seu bolso, que informou o local onde foram apreendidos os demais entorpecentes e foi conduzido à delegacia. Falou que comercializava vendia cada invólucro de maconha por R\$ 5,00, a porção de cocaína por R\$ 10,00, o invólucro de "crack" por R\$ 5,00 e o tubo de lança-perfume por R\$ 5,00. Informou que foi preso por tráfico de drogas em 2014 e 2016, tendo cumprido pena e deixado a prisão em 2018. Declarou que estava trabalhando e longe da criminalidade, mas que a necessidade financeira o fez retornar ao tráfico.

Em juízo, confessou que estava traficando por necessidade e agiu por "emoção", pois não arrumava emprego em razão da pandemia. Afirmou que vendeu R\$15,00 e quando foi abordado pelos policiais estava com 4 de cocaína e 1 de maconha. Disse que indicou para os policiais onde estava o restante das drogas (do outro lado da rua, escondidas dentro de um cano em uma sacola. Tem condenação por tráfico, mas já cumpriu a pena e saiu da cadeia em 2018. Nada tem contra os policiais.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico, estavam em operação com viatura descaracterizada quando se depararam com o réu, que aparentava estar nervoso, e resolveram abordá-lo.

Relataram que em abordagem localizaram em poder do réu a quantia de R\$ 17,00, 04 invólucros de cocaína e 01 invólucro de maconha. Falaram que o réu confessou que estava traficando as drogas, dizendo que era seu primeiro dia no local, e informou que guardava mais drogas em um cano, do outro lado da rua. Afirmaram que no local indicado localizaram uma sacola plástica contendo outros tipos de entorpecentes ("crack" e lança-perfume).

William (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, fizeram campana por uns 15 minutos e só o réu no local atento, olhando para os lados e o abordaram. Disse que em poder do réu havia 4 de cocaína, 1 de maconha e R\$17,00. O réu confessou o tráfico, informou que era seu primeiro dia e indicou do lado da rua onde havia mais drogas ("crack", maconha, cocaína e lança perfume). O total de drogas era em torno de 70 porções no total. Não conhecia o réu anteriormente. O local é uma rua do "Morro do Samba" e havia pessoas passando normalmente. Informou que o restante das drogas estavam escondidas num cano dentro de uma sacola.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Adriano. Havia pessoas passando normalmente e não viram o réu em movimento de tráfico, apenas desconfiaram por estar parado em local conhecido como ponto de tráfico e olhando para os lados. Não conhecia o réu anteriormente.

O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Além disso, o fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 21 - 32 porções de maconha, 15 invólucros de cocaína, 17 pedras de "crack" e 05 tubos de lança-perfume) e diversidade (cocaína, cocaína, "crack" e lança-perfume), aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em porções, que foi apreendido dinheiro não sendo provada a sua procedência, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa grande quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Apesar das ponderações da defesa em razão da grande quantidade de ocorrências que atendem, nem sempre é possível os policiais se recordarem de todos os detalhes. Porém, foram uníssonos no sentido de que aprenderam o réu com dinheiro e poucos entorpecentes, que ele confessou o tráfico e apontou onde mantinha escondida uma sacola com as drogas.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para os crimes dos art. 28 ou 37, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (32 porções de maconha, 15 invólucros de cocaína, 17 pedras de "crack" e 05 tubos de lança-perfume) demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 27/29) e laudo definitivo (fls. 82/84).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 33 - proc. 497-96.2016).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e a confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.ª Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESp N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que a condenação anterior também é por tráfico. Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (fls. 33 – proc. 497-96.2016), o que denota personalidade voltada para crimes de tráfico, o qual é seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos diante do montante da pena e por ser reincidente específico.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 04.11.21, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 03.11.23).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas

também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JONATHAN DA SILVA MACEDO à pena de 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou atividade lícita nem residência fixa) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 21 e 57) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 42), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 14 de março de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA